

0009707-75.2021.8.26.0577

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Crimes do Sistema Nacional de Armas

Magistrado: José Loureiro Sobrinho

Comarca: São José dos Campos

Foro: Foro de São José dos Campos

Vara: 1ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 19/01/2022

... materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para cocaína e maconha, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu, interrogado, negou a acusação de tráfico. Disse ser trabalhador, atuando no ramo de segurança privada e de lanches. ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de São José dos Campos

Foro de São José dos Campos

1ª Vara Criminal

Av. Salmão, 678, São José dos Campos-SP - cep 12246-260

Horário de Atendimento ao Público: das 12h30min às 19h00min

505088 sentença genérica base crime 1231 0009707-75.2021.8.26.0577 - lauda
SENTENÇA

Processo Digital nº:

0009707-75.2021.8.26.0577

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Crimes do Sistema Nacional de Armas

Documento de Origem:

Comunicação de Prisão em Flagrante, Comunicação de Prisão em Flagrante, Boletim de Ocorrência, Comunicação de Prisão em Flagrante - 2044775/2021 - DISE- DEL.SEC.S.J.

DOS CAMPOS, 16256709 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 30/21/328 - DISE-

DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS, 2044775 - DISE- DEL.SEC.S.J. DOS CAMPOS

Tipo Completo da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>:

Nome da Parte Ativa Principal << Informação indisponível >>

Réu:

ANDRÉ LUÍS BARBOSA

Réu Preso

Tramitação prioritária

Juiz(a) de Direito: Dr(a). José Loureiro Sobrinho

Vistos.

1.VINICIUS SILVA e ANDRÉ LUÍS BARBOSA, qualificados nos autos, foram denunciados como incurso no artigo 33, "caput", e artigo 35, "caput", ambos da Lei 11.343/06, porque na data e local descritos na denúncia, agindo com consciência e vontade livres, após associaram-se para o fim de cometerem tráfico ilícito, de forma reiterada ou não, tinham em depósito, substâncias entorpecentes, a saber e respectivamente, 03 porções de maconha, 01 porção de cocaína, 03 pedras de crack e 08 tijolos de maconha, para o fim de comércio ilícito, sem autorização e em desacordo com determinação legal; sendo que VICICIUS SILVA, qualificado nos autos, foi também denunciado como incurso no artigo 12, da Lei 10.826/03, porque na data e

local descritos na inicial possuía arma de fogo, a saber, uma pistola Glock, 9mm, mais 105 munições intactas do mesmo calibre.

O réu Vinicius foi notificado, sendo o feito desmembrado quanto ao André Luís, por estar em l.i.n.s., prosseguindo nestes apenas com relação a ele.

Uma vez encontrado, cumprido devidamente o mandado de prisão preventiva, foi o réu André Luís notificado.

Defesa prévia foi apresentada.

A denúncia foi recebida.

O réu foi citado e, em audiência de instrução debates e julgamento, foram ouvidas testemunhas arroladas pela acusação e pela defesa, procedendo-se, enfim, ao interrogatório.

Em debates, o representante do Ministério Público pleiteou a procedência da ação penal, nos termos da denúncia, com a consequente condenação dos réus. A defesa pugnou pela absolvição, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal, ou, subsidiariamente, a redução máxima de pena prevista na Lei de Drogas, substituição da privativa de liberdade por restritiva de direitos e concessão do direito de recorrer em liberdade.

É o relatório.

DECIDO.

2.A ação penal deve ser julgada parcialmente procedente.

A materialidade do delito de tráfico está comprovada pelo laudo de exame químico toxicológico de fls., que apontou resultado positivo para cocaína e maconha, não merecendo reparo, pois bem se utilizou da boa técnica existente.

A autoria é indubitosa.

O réu, interrogado, negou a acusação de tráfico. Disse ser trabalhador, atuando no ramo de segurança privada e de lanches. Destacou que na data dos fatos quando retornou à sua casa soube da diligência policial em questão, frisando que em sua residência, que estava toda revirada, não havia qualquer droga. Enfim, negou qualquer envolvimento com o tráfico de drogas.

A prova oral, por sua vez, corroborou os fatos descritos na denúncia.

As testemunhas ouvidas, notadamente os policiais civis, de maneira firme e coerente, informaram que a polícia militar realizou prisão de indivíduos com razoável quantidade de drogas. Assim, em celulares apreendidos e devidamente periciados foi apurado que indivíduo, cujas características corresponderiam às do réu Vinicius estaria envolvido com o tráfico, buscando compra e venda de drogas de forma reiterada e em razoável quantidade. Então, em diligência de campo foi apurado que o réu se dirigia à casa do corréu André Luís e que em determinada ocasião lá deixou uma sacola. Diante disso, com regular mandado de busca, na casa de André Luís, que estava ausente, foram achados oito tijolos de maconha, pesando aproximadamente 3,5 kg. Já na casa de Vinicius foi achado o restante da droga, bem como caderno com anotações típicas do tráfico, com entrada e saída de mercadoria, bem como um celular. No aludido celular periciado foi apurado que o réu realizava diversas conversas, visando compra e venda de droga, fazendo tal seu meio de vida, destacando-se que trabalhava com o sistema de amostras, tudo levando a crer que aquela droga achada em sua casa destinava-se a tal fim. Além disso, na casa havia R\$ 1.500,00, e uma arma de fogo e as munições destacadas na inicial. Diante disso, foi o réu Vinicius conduzido preso à Delegacia de Polícia.

A completar o conjunto probatório degravação de conversas no telefone do réu, via WhatsApp, juntada a fls.

Já as testemunhas arroladas exclusivamente pela defesa, todas amigas do réu, deram conta que ele não traficava drogas e que trabalhava lícitamente no comércio de lanches, pouco ou nada acrescentando ao conjunto probatório, não sendo demais dizer, desde já, que tais depoimentos não podem ser levados em conta por suspeitos, tendo em vista a proximidade dos depoentes com o acuado.

Diante desse quadro, percebe-se que o conjunto probatório aponta, de forma suficiente, terem os réus realizado o delito previsto no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, em suas elementares, na forma descrita na denúncia.

O conceito de suficiência, não se confunde, para efeito de condenação, com isenção

total de eiva indubitativa, consiste, pois, na firme possibilidade de afirmação da realidade do fato imputado e de definição de sua autoria, no contexto das comprimidas fronteiras humanas da capacidade de apreensão dos elementos probatórios e de reconstituição do episódio delituoso. Prova suficiente não é nem pode ser penhor de certeza plena, de que somente os deuses são senhores. Daí se afigura irreal e meramente retórico o emprego de expressões como "prova categórica", "prova cabal", e outras do gênero.

Bem assim, há prova suficiente de que a substância entorpecente foi encontrada em poder dos réus, o que, por si só, autoriza a condenação.

Autoriza porque, desta forma, o réu praticou a conduta típica prevista no artigo 33, da Lei 11.343/06, incidindo em pelo menos um dos verbos descritos na figura típica, qual seja, "ter em depósito".

O fim específico de tráfico não é elemento subjetivo do tipo, o qual não prevê dolo específico, decorrendo da subsunção da conduta a um dos verbos descritos nele. O tráfico está assim caracterizado, devendo-se comprovar o elemento específico apenas nos casos do artigo 28, da Lei 11.343/06, ou seja, o uso próprio.

Mas, mesmo se assim não fosse, o fim de mercancia ilícita está demonstrado ante as peculiaridades do caso, ou melhor, a quantidade, a diversidade e a forma em que o entorpecente estava separado e acondicionado, bem como e notadamente as campanhas policiais e as degravações de conversas, onde se observa que o réu Vinicius comprava e vendia drogas reiteradamente, em ação coordenada, em divisão de tarefas, entregando-a, inclusive ao corréu André Luís, fazendo ambos do tráfico seu meio de vida, apontam para fins de comercialização, para repasse a terceiros.

O fato da substância entorpecente ter sido encontrada em poder do réu, inverte o ônus da prova, impondo-lhe justificativa verossímil, fazendo incidir sobre ela presunção de culpabilidade.

No caso presente, os réus não fizeram prova suficiente nesse sentido, pois se invertendo o ônus da prova, a suficiência probatória, agora para afastar ou, pelo menos, estabelecer a dúvida sobre a acusação, compete a ele.

Não se diga, ainda, que o testemunho de policiais deva ser recebido com reservas. A simples condição de policial não torna a testemunha impedida ou suspeita. Pelo contrário, o testemunho de policiais deve merecer credibilidade, pois não faz sentido que eles, credenciados pelo Estado para atuarem na repressão e na prevenção delitiva, sejam desconsiderados, quando compromissados, como qualquer outra testemunha, que vêm a juízo relatar diligências a que procederam no exercício de suas funções.

Quanto à co-autoria, frise-se que, nos termos do artigo 29, "caput", do Código Penal, quem, de qualquer modo, concorre para o crime, incide nas penas a este cominadas, na medida de sua culpabilidade.

"Co-autoria 'é a realização conjunta de um delito por várias pessoas que colaboram consciente e voluntariamente' (Muñoz Conde, Teoría General del Delito, 1984, pg. 292). Cada co-autor é um autor e, por isso, deve apresentar as características próprias do autor. Isto significa que o co-autor 'é aquele autor que tem o domínio da realização do fato conjuntamente com outro ou outros autores, com os quais tem um plano comum e uma distribuições de funções na realização do mútuo acordo' (Juan Bustos Ramirez, Manual de Derecho Penal Español, 1984, pg. 331)".

"A co-autoria é nada mais nada menos, em última análise, a própria autoria. Funda-se ela sobre o princípio da divisão do trabalho; cada autor colabora com sua parte no fato, a parte dos demais, na totalidade do delito e, por isso, responde pelo todo. Há na co-autoria, a decisão comum para a realização do resultado e a execução da conduta".

Diante do conjunto probatório, tudo leva a crer que os corréus são coautores, porque, de qualquer modo, contribuíram para o crime, estando previamente associados entre si e com unidade de propósitos, tendo o domínio final do fato típico, o qual praticaram, não podendo ser considerados como meros partícipes, vez que nenhum deles simplesmente apenas contribuiu auxiliando a conduta do outro.

Por outro lado, comprovado não está o delito previsto no artigo 35, "caput", da Lei 11343/06.

Não é o simples concurso de pessoas que caracteriza associação. Necessário é o

“animus” associativo prévio, sem dúvida uma “societas sceleris”. Necessária é a comprovação de tal elemento do tipo, ou seja, vínculo associativo de caráter permanente, duradouro, que se depreende de vários elementos tais como reuniões prévias, base de operação, níveis de lucros presumidos, etc., o que não corre nos autos.

No mais, em razão das peculiaridades do caso, tudo leva a crer que o dinheiro encontrado era produto do ilícito, não se logrando provar o contrário, ou seja, sua origem lícita, sendo de rigor seu perdimento a favor da União, como efeito da condenação, nos termos do artigo 91, II, “b”, do Código Penal.

Destarte, comprovadas a materialidade e a autoria pelo delito de ogo e tráfico, nos exatos termos da fundamentação supra, impõe-se a condenação e por insuficiência probatória se impõe a absolvição quanto ao crime de associação para tal fim.

Na aplicação da pena, sopesadas as circunstâncias do artigo 59, do Código Penal, as penas-bases devem ser fixadas no mínimo legal.

Aqui, bom destacar que a causa de redução prevista no artigo 33, § 4º, da lei 11.343/06, não se aplica ao caso, não sendo demais lembrar haver prova bastante de se dedicarem os réus a ações ilícitas, tendo em vista as informações e a própria degravação telefônica, aliada ao fato do encontro de anotações, dando conta que se dedicava a atividade criminosa, demonstrando de forma evidente que estavam a fazer do odioso tráfico de drogas seu meio de vida.

Em razão das condições econômicas do réu, a unidade do dia multa deve ser fixada no mínimo legal, devendo ser aplicado, neste ponto, o previsto na Lei 11.343/06, em razão do princípio da especialidade.

Essa pena, assim, devem ser tornadas definitivas, na ausência de outras condições modificadoras.

3. Posto isso, julgo PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação penal e

ABSOLVO o réu ANDRÉ LUÍS BARBOSA, qualificado nos atos, da imputação a ele feita na denúncia pela infração penal prevista no artigo 35, da Lei 11.343/06, e o faço por insuficiência de provas, nos termos do artigo 386, VII, do Código de Processo Penal;

CONDENO o réu ANDRÉ LUÍS BARBOSA, qualificado nos autos, como incurso no artigo 33, “caput”, da Lei 11.343/06 à pena de cinco anos de reclusão e quinhentos dias-multa, com unidade fixada no mínimo legal.

Não faz o réu jus ao benefício da substituição da pena privativa de liberdade, nos termos do artigo 44, do Código Penal, pois o crime de tráfico de drogas é grave, equiparado inclusive ao hediondo. Mesmo se isso não bastasse, o delito em questão está capitulado em Lei Especial (nº 11.343/06), e tal, em seu artigo 33, § 4º, veda expressamente o aludido benefício, o qual nada tem de inconstitucional, pois apenas atende ao princípio de individualização da pena, observando a grávida intrínseca do crime em questão, isso sem dizer, é claro, da quantidade de pena aplicada e do concurso de agentes.

Pelos mesmos motivos, o regime inicial para cumprimento das penas deverá ser o fechado, nos termos do artigo 33, § 3º, do Código Penal e artigo 2º, § 1º, da Lei 8.072/90, com a nova redação que lhe foi dada, mas notada e precipuamente, porque assim recomendam os elementos concretos e individualizados, ante a gravidade do tráfico em questão, que na situação concreta, não provém de simples abstrações, suposições ou meras presunções, mas, sim, da situação fática descrita na denúncia, consistente na apreensão de razoável quantidade de droga diversa, acondicionada em diversos invólucros, droga essa destinada à venda reiterada, em ação coordenada, com divisão de trabalho, o que não só põe em relevo a periculosidade do agente, como também justifica e autoriza regime inicial mais gravoso.

Também pelos mesmos motivos, não tem os réus o direito de apelar em liberdade, tendo em vista estarem presentes os requisitos da custódia cautelar, notadamente a garantia da ordem pública, ante a gravidade do delito em questão, tráfico ilícito de cocaína e maconha, de nefastas consequências para a sociedade, a qual, assim, deve ser preservada, não sendo demais lembrar se dedicarem os réus a atividades criminosas e a cumulação deste delito com porte ilegal de arma, o que, no caso, somente potencializa a gravidade dos crimes em tela.

Determino, ainda, o perdimento, a favor da União, do dinheiro apreendido, nos termos do artigo 91, II, "b", do Código Penal, devendo-se ser entregue ao Fundo Nacional Antidrogas - FUNAD, procedendo-se nos termos do artigo 60 e seguintes, da Lei 11.343/06.

P.R.I.C.

São José dos Campos, 19 de janeiro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA